

0034471-96.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0034471-96.2017.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0034471-96.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF, IP-Flagr. - 2279/2017 - 3º Distrito Policial - Santa Ifigênia, 326/2017 - 3º

Distrito Policial - Santa Ifigênia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WASHINGTON DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

WASHINGTON DE JESUS, R.G. 71.163.558, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, isto porque, no dia 27 de abril de 2017, por volta das 13h30min, na Rua Guaianases, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para consumo de terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, seis invólucros de papel alumínio contendo maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica.

Segundo se apurou, policiais civis que passaram pelo local dos fatos, avistaram o acusado e outro indivíduo em atitude suspeita e quando deles se aproximaram, os dois correram, cada qual para um lado. Alcançados, abordados e revistados, em poder de Washington foram encontradas as seis porções de maconha e a quantia em espécie de R\$ 10,00. Com o outro indivíduo, Robson Monteiro Nogueira, nada foi encontrado. Questionado, o denunciado admitiu informalmente que estava praticando o tráfico de

drogas. Ouvido na delegacia, Robson confirmou que compraria maconha do acusado, informando que chegou a entregar-lhe a nota de R\$ 10,00, mas que não recebeu a sua porção de entorpecente em razão da aproximação policial.

Lavrado o auto de prisão em flagrante delito (fls. 04/05), o acusado recebeu nota de culpa (fls. 18), foi qualificado e pregressado (fls. 19/26).

Oferecida a denúncia de fls. 01/02, que veio acompanhada dos autos do inquérito policial de fls. 03/45, o acusado foi notificado, vindo aos autos, no prazo legal, a defesa preliminar de fls. 172/173, subscrita por Dra. Defensora Pública nomeada.

A denúncia foi recebida por despacho no dia 13 de agosto de 2019 (fls. 178/179).

O réu foi citado pessoalmente, fls. 195.

Durante a instrução da causa foram tomados os depoimentos de tres testemunhas arroladas pela acusação, no caso dois policiais ouvidos em São Paulo e uma testemunha ouvida por precatória cujo link de acesso se encontra a fls. 370 (https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lgalassi_tjsp_jus_br/EdEQrT9RmdJv8R1nxJIFPIBtg3Lj2hqDtkdD4ooPH7jLw?e=OCSyY9).

O acusado foi interrogado ao final da instrução.

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes em alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denuncia e a Defesa requereu a absolvição. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para uso de substancia entorpecente. Em caso de condenação requereu o privilégio, regime aberto e recurso em liberdade.

Encontram-se, ainda, nos autos, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 12/14); o auto de exibição e apreensão (fls. 15); laudo provisório, fls. 62/63 o laudo do exame químico-toxicológico (fls. 97/99); bem como as folhas de antecedentes criminais do acusado (fls. 87/89).

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 conforme mais adiante se verá.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls.15) e dos laudos de constatação provisória (fls. 62/63), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de substancia entorpecente (fls. 97/99), com resultados positivos para TETRAHIDOCANNABINOL (THC).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes colhidos na fase inquisitiva.

Walter, policial civil, reconheceu o acusado em audiencia de uma ocorrência de 2017. Estavam na delegacia e próximo ao local dos fatos sabem que há venda de drogas, ponto de troca de celular e de coisas ilícitas. Estavam por ali a pé sendo que se depararam com uma situação suspeita entre duas pessoas. O depoente foi atrás do acusado e o parceiro atrás de Robson. Pelo que viu era o acusado quem estava vendendo a droga porque ele recebeu uma nota de dinheiro do outro. Presenciou washington pegando 10 reais da testemunha. Os dois, ao perceberem a presença da policia, correram, cada um para um lado. Abordou o réu e com ele encontrou o entorpecente e a nota de 10,00 reais. Ele admitiu informalmente que é usuário e que vende droga para sustentar seu vicio. A testemunha foi presa em flagrante e no local confirmou que havia comprado droga do réu.

Flávio, o outro policial, declarou que no dia dos fatos viu o acusado com uma outra pessoa. Os dois aparentavam estar negociando algo. Deu para ver que foi Robson quem entregou dinheiro a Washington. Os dois correram ao perceberem a presença dos policiais. Abordou Robson e com ele nada foi localizado. Ele declarou que estava comprando maconha mas que não houve tempo de pegar a droga.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do acusado. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória

consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96).

A testemunha Robson, ouvida por precatória, em resumo disse o seguinte:

"Que não conhece o acusado e que nunca o viu. Sempre visitou os parentes em São Paulo. É consumidor de drogas. Disse que não conhece Washington. Não comprou drogas de ninguém em São Paulo. Recorda-se que esteve na Galeria do Rock, foi abordado pelos policiais e com ele se encontrava 10 reais r o . Disse que foram os policiais que deram o depoimento que assinou. O entorpecente estava com o depoente mas a droga era dele. Nunca viu o réu. Não se recorda da abordagem. Não sabe se ele tinha droga. Na hora da abordagem não estava próximo de ninguém e sim com DEUS.

Por fim, Washington declarou tem 40 anos de idade. É solteiro. Não tem filhos. Trabalha com reciclagem ou trabalha de ajudante. Estava morando na rua, no Jardim Angela. Se afastou da família por causa das drogas. O entorpecente que foi encontrado consigo era para seu uso próprio. Tinha comprado de Robson. Está preso por tráfico e associação, a 6 anos e 9 meses. J'foi internado em um clinica de recuperação e ficou 21 dias. Acabou saindo antes de curar. Teve recaída. Estava sem dormir há uma semana. Sua versão não encontra respaldo nos autos até porque não foi confirmada por Robson e infirmada pelos policiais civis que presenciaram atos de mercância por parte do acusado.

Daí porque, confrontados os elementos de prova, afigura-se de rigor a condenação. Passo a dosar a pena:

Fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que os tipos de entorpecente apreendidos em posse dele bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente já está previsto no tipo penal. Portanto, quanto a este aspecto, discordo da posição trazida pelo Ministério Público.

Em segunda fase, afasto a agravante referente a calamidade publica eis que, a meu sentir, não houve prova alguma de que o circunstancia tenha agravado o crime ou facilitado sua pratica. Não há prova de nexo causal. De igual forma, a confissão e a menoridade relativa não serão utilizadas para o fim de se diminuir a pena aquém do mínimo lega.

Em terceira fase, pesem as ponderações trazidas pelo Ministério Público, entendo que é o caso de aplicação do trafico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu é primário e não possui maus antecedentes, fls.29/31. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrasse organização criminosa. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou portador de maus antecedentes, bem como de integrante de organização

criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico para se atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaiam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em si. E, seguido-se esse entendimento, no caso em apreço, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, é a máxima, ou seja, 2/3.

Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida. Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena pois entendo ser suficiente a, no caso concreto, coibir a prática delitiva.

Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. Isto porque, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 1.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida” (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Consequentemente, concedo o apelo em liberdade.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno WASHINGTON DE JESUS, R.G. 71.163.558, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, “caput” e § 4º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal, estes corrigidos desde a data do fato.

Outrossim, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu, que claramente praticava o comércio de drogas é

insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal. O réu praticou crime gravíssimo, sendo com ele apreendido drogas de alto potencial lesivo, droga esta capaz de atingir a um sem-número de usuários e viciados. Assim, pelas circunstâncias concretas do crime, não há indicação de que tal substituição ou seja suficiente ou recomendável.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Decreto o perdimento do valor apreendido (fls.15). Encaminhe-se ofício ao SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/06;

Transitada esta em julgado tornem conclusa para a designação de data para audiência admonitória.

Recurso em liberdade..

Isento de custas.

Publicada em audiência.

São Paulo, 08/06/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA